

1500376-86.2020.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... ser analisada com atenção especial nos casos que envolvam tráfico de drogas - sem descartar o cuidado em relação a outros crimes permanentes. É que o tráfico de drogas é um crime cujo núcleo do tipo é misto ou alternativo, ou seja, pode se consumir com a prática de qualquer uma das várias ações descritas no tipo penal. Veja que o caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500376-86.2020.8.26.0558 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500376-86.2020.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2232231/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 13675036 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

4324/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2232231 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

4324/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO DE OLIVEIRA DOTTI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

FABIO DE OLIVEIRA DOTTI, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006, pois no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 18h10, na Avenida Casa Branca, 135, Jardim Del Rei, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, trouxe e guardou consigo drogas, consistentes em 20 (vinte) invólucros de maconha e um tijolo da mesma droga, para fins de comércio ilícito com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, o denunciado trazia consigo um tijolo de maconha e guardava em sua residência mais vinte porções da mesma droga, para comércio com terceiros, quando foi surpreendido pela Polícia Militar. Policiais militares receberam uma informação anônima de que um homem, conhecido como Fábio Dotti,

estava vendendo drogas na avenida do aeroporto. Chegando ao local, encontraram o denunciado em atitude suspeita. Ao notar a presença dos militares, o denunciado dispensou um objeto e foi abordado. Em revista inicial nada de ilícito foi encontrado, porém o objeto dispensado se tratava de uma chave do veículo TOYOTA/Corolla. Em buscas no veículo foi encontrado um tijolo de maconha. Fábio teria confessado a traficância e a existência de mais droga em sua residência, razão pela qual os policiais se dirigira até lá e encontraram 20 (vinte) invólucros de maconha, em meio a uma blusa feminina.

Levada a efeito a prisão em flagrante, houve sua homologação, concedendo ao autuado o benefício da liberdade provisória, sem fiança.

Manifestação da defesa pela concessão do Acordo de Não Persecução Penal (fls. 111/123), sem oferecimento em denúncia.

O acusado foi notificado (fls. 190) e apresentou defesa preliminar (fls. 167/183), momento em que pleiteou também pela remessa dos autos dos autos ao Procurador Geral de Justiça, que se manifestou em fls. (192/201) insistindo na recusa de oferta do acordo.

Áudios juntados em fls. 220.

A denúncia foi recebida em fls. 239/240, em 12 de abril de 2021.

Houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento. Neste ato, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e o acusado foi interrogado (fls. 289/290 e fls. 483/487).

Manifestação da defesa (fls. 291/297) pela realização de perícia de Voz e Comparação Fonética. Manifestação do Ministério Público (fls. 301/305) pelo indeferimento do pedido.

Laudo de Comparação Forense de Locutor (fls. 345/365).

Manifestação do Ministério Público (fls. 373).

Manifestação da Defesa (fls. 374/396).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos expostos na denúncia (fls. 495/499) e a defesa pleiteou pela oferta de Acordo de Não Persecução Penal, aduzindo ainda ocorrência de flagrante preparado.

É o relatório.

DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

Na fase policial (fls. 3), a testemunha CELIO VICTOR DA MOTA, policial militar, disse que realizava patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega de farda Sd/PM Maxwell, quando foram averiguar denúncia de tráfico de drogas ocorrido no final da avenida do aeroporto, neste município, o indivíduo de nome Fábio Dotti estria vendendo drogas naquele local. De posse dessa informação, afirma o miliciano que deslocou até o local, avistou o indiciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOTTI em atitude suspeita e, por isso, resolveram abordá-lo. Em seguida, afirma o militar que, momentos antes da abordagem, esse indivíduo atirou algo no chão e, após efetuarem busca pessoal no indiciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOTTI; porém nada de ilícito foi encontrado, mas encontraram o que ele havia jogado, ou seja, as chaves de um veículo TOYOTA/Corolla. Em seguida, efetuaram buscas no automóvel e encontraram: 01(um) "tijolo" da droga "maconha", embalada para a venda. Após a localização, informa o miliciano que indagou o indiciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOTTI sobre a droga e ele confirmou que a droga lhe pertencia e alegou que iria vendê-la a um indivíduo naquele local e confessou que na sua casa havia mais drogas em depósito.

Incontinente, os policiais rumaram até à casa do indiciado e encontraram: 20(vinte) porções de diferentes tamanhos da droga "maconha", embaladas para a venda; 01(uma) balança de precisão e a quantia de R\$ 988,00(novecentos e oitenta e oito reais).

Ainda, disse o policial que indiciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOTTI afirmou que na casa dos pais deles havia mais 02(duas) porções da droga "maconha", embalada para a venda. Diante do cenário, o depoente deu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas ao indiciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOTTI conduzindo o implicado a esta Delegacia de Polícia.

Na fase policial (fls. 4), a testemunha MAXWELL ROBERTO ALMEIDA DOMINGUES, policial militar, disse que realizava patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega de farda Cb/PM Célio, quando foram averiguar denúncia de tráfico de drogas ocorrido no final da avenida do aeroporto, neste município, o indivíduo de nome Fábio Dotti estria vendendo drogas naquele local. De posse dessa informação, afirma o miliciano que deslocou até o local, avistou o indiciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOTTI em atitude suspeita e, por isso, resolveram abordá-lo. Em seguida, afirma o militar que, momentos antes da abordagem, esse indivíduo atirou algo no chão e, após efetuarem busca pessoal no indiciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOTTI; porém nada de ilícito foi encontrado, mas encontraram o que ele havia jogado, ou seja, as chaves de um veículo TOYOTA/Corolla. Em seguida, efetuaram buscas no automóvel e encontraram: 01(um) "tijolo" da droga "maconha", embalada para a venda. Após a localização, informa o miliciano que indagou o indiciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOTTI sobre a droga e ele confirmou que a droga lhe pertencia e alegou que iria vendê-la a um indivíduo naquele local e confessou que na sua casa havia mais drogas em depósito.

Incontinentemente, os policiais rumaram até à casa do indiciado e encontraram: 20(vinte) porções de diferentes tamanhos da droga "maconha", embaladas para a venda; 01(uma) balança de precisão e a quantia de R\$ 988,00(novecentos e oitenta e oito reais). Ainda, disse o policial que indiciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOTTI afirmou que na casa dos pais deles havia mais 02(duas) porções da droga "maconha", embalada para a venda. Diante do cenário, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas ao indiciado FÁBIO DE OLIVEIRA DOTTI conduzindo o implicado a esta Delegacia de Polícia.

Na fase policial (fls. 5), o interrogado disse que não possui advogado, indicou sua pai Luiz Alberto Dotti para ser avisado sobre sua prisão o qual estava presente neste Plantão Policial e foi comunicado desse fato, disse não ter filhos. Sobre o fato, exerceu seu direito de permanecer calado e somente se manifestar após receber orientação de um advogado ou defensor público.

A materialidade está bem retratada nos autos conforme restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito de fl. 02, boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, fotografias de fls. 13/17, laudo de constatação de fls. 19/20, comprovante de depósito judicial de fl. 40, laudo de exame químico toxicológico de fls. 41/43, além da prova oral colhida nos autos.

A autoria do delito é incontestável, vez que a prova é coesa e firme nesse sentido. Com efeito, a testemunha CELIO VICTOR DA MOTA, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelas imediações da avenida Casa Branca, tendo sido parado por um solicitante informando que alguns dias via observando um indivíduo com as mesmas características fazendo comércio de entorpecente naquele local, dizendo ainda que tinha passado há poucos instantes pelo local e o indivíduo ainda se encontrava por lá, encostado em um carro preto, de camiseta branca e bermuda. Diante dessas informações, deslocou-se até o local, realizando o patrulhamento com vistas, quando visualizaram um indivíduo de camiseta branca e bermudas, que ao ver a viatura se assustou e jogou um objeto ao solo, chamando a atenção da equipe, iniciando a abordagem nele. Em revista pessoal, nada foi encontrado. O policial Maxwell procurou no terreno onde visualizaram o indivíduo jogando o objeto, localizando uma chave de um veículo TOYOTA, quando destravou um COROLLA, logo a frente da abordagem. Realizada a vistoria no veículo foi localizado no encosto de braço central do veículo, um tijolo de maconha. Indagado sobre o entorpecente, o indivíduo confessou que estaria ali para realizar a venda daqueles entorpecentes, informando ainda que na sua residência havia mais entorpecentes. Diante disso, deslocaram-se até o local, tendo o indivíduo franqueado a entrada da equipe na residência, indicando que dentro da cozinha, dentro de uma caixa de sapato havia mais entorpecentes onde foi localizado a quantia de 20 pedaços de maconha de diferentes tamanhos, R\$ 998,00 e uma balança de precisão. O indivíduo informou que cada pedaço costumava ser vendido entre R\$ 50,00 a R\$ 100,00 de maconha. Informou ainda que dentro da casa dos pais tinha mais um restante de entorpecente. Foi pedido apoio, com deslocamento até a casa do pai, onde o réu ainda teria um quarto, tendo sido localizado dentro de um pote de suplementos mais 2 invólucros de maconha

semelhantes aos que estavam em sua residência, totalizando 1,2kg de maconha. Diante dos fatos, foi conduzido ao plantão e o delegado ratificou a voz de prisão. Disse que o conhecia de vista da cidade. Que não conhece Letícia Peralta. Disse que ninguém fez contato com réu via WhatsApp com objetivo de agendar a compra de entorpecente.

Em juízo, a testemunha MAXWELL ROBERTO ALMEIDA DOMINGUES, policial militar, arrolada pela acusação, disse que estava em patrulhamento de força tática pelo bairro ali do aeroporto, quando um transeunte parou a viatura informando que tinha um indivíduo vários dias vendendo drogas ali no final do aeroporto, na avenida casa branca, passando as características e passando o veículo. Diante dessas informações, estavam em patrulhamento com vistas, quando visualizaram o Fábio, o qual, ao visualizar a viatura, ficou nervoso e dispensou um objeto no chão, pelo que realizaram a abordagem. Em busca pessoal nada foi encontrado. Porém, encontrou a chave do veículo logo a frente, um TOYOTA COROLLA, destravando o carro. Disse que seu companheiro, cabo Célio, fez a busca veicular, onde foi encontrado um tijolo de maconha. Ao ser indagado, Fábio confessou que estava ali para venda dessa droga para um indivíduo, indicando ainda que na sua residência teria mais drogas. Então, deslocaram-se para o local, onde Fábio franqueou a entrada dos policiais indicando onde estariam as demais drogas, estando em um armário dentro da cozinha numa caixa de sapato, com 20 invólucros de maconha em diferentes tamanhos e que Fábio vendia essas drogas entre R\$ 50,00 a R\$ 100,00. Também foi encontrada uma balança de precisão e Fábio indicou que na residência de seus pais tinha um quarto que teria mais maconha. A equipe da Rocan se deslocou até a residência encontrando mais maconha num pote de suprimento. Disse que não conhecia Fábio de antes. Disse que não sabia sobre relacionamento amoroso entre Letícia e Célio. Disse que não enviou WhatsApp para acusado.

Em juízo, a testemunha JOÃO VITOR ELOY DO SANTOS, arrolada pela defesa, disse que sabe que o Fábio é cunhado da Raquel. Disse que estava na casa de sua ex-mulher, que era de madrugada, não sabendo dizer o horário. Disse que estava dormindo, com muito barulho de carro na vila, um correndo atrás do outro. Sua ex-mulher foi para fora ver o que estava acontecendo, quando se iniciou um "converseiro", tendo sido o momento que ele saiu, estando o Fábio e o Policial Célio, que estava sem farda, num gol quadrado. Os dois estavam discutindo. A ex-mulher dele entrou no meio, porque é cunhada do Fábio. Os dois começaram a brigar, foi ainda que ele entrou no meio também, afastando sua mulher e tentando separar Fábio e Célio. Que observou que o Célio estava com uma faca ou alguma coisa assim. Pediu para os dois pararem que iriam acordar as crianças. Ai o Célio foi embora. O Fábio conversou um pouco com a testemunha e também foram embora. Disse que os dois quase se mataram, especialmente porque o Célio estava armado. Disse que o Fábio relatou que o motivo era a esposa do Fábio, que foi namorada de Célio. Que a situação foi na casa da Raquel.

Em juízo, a testemunha LETÍCIA ARAÚJO PERALTA, arrolada pela defesa, disse que é esposa de Fábio, prestando depoimento como informante, disse que já manteve relacionamento com Célio. Que trabalhava atendente num restaurante, na avenida do Aeroporto, chamado The Black Chip, quando Célio começou trabalhar lá fazendo bico de segurança para fechamento de caixa. Disse que mantiveram o relacionamento pelo período de 11 meses. Disse que o término do relacionamento se deu porque Célio não assumia publicamente e ficava dando desculpas, até que descobriu que ele era casado. Que, no começo, Célio aceitou, mas depois de ¾ dias começou a perturbá-la, ligando várias vezes no celular, frequentar os lugares por onde ela estava passando, tanto com carro pessoal como com carro da polícia. Disse que o Célio perseguia ela e o Fábio, que tinha noites que o celular dela tentava interromper, falando que a hora do Fábio iria chegar. Que o Célio já foi na porta da casa, até entrando na sua casa sem autorização, para colocá-la na parede.

Em juízo, o réu FÁBIO DE OLIVEIRA DOTTI disse que é vigilante, ganhando por mês em torno de R\$1.600,00 a R\$ 2.300,00 reais. Disse que não tem filhos. Nunca foi preso ou processado. Disse que conheceu uma menina que teve envolvimento com a polícia da força tática, mas não sabia. E começou chegar umas mensagens no celular dele pedindo maconha. Pediu uma certa quantia, de meio quilo, mais ou menos. Que ele conhece todo mundo, porque mora ali na periferia. Que na época estava desempregado.

Hoje está trabalhando, vendo uma oportunidade de ganhar uma grana. Pediram uma amostra. Cortou um pedaço e foi até aeroporto, local dos fatos. Chegando lá foi abordado por várias viaturas, estando o Célio, que pediu para assumir a ocorrência. Disse que recebeu no celular uma encomenda de droga. Disse que não sabia quem tinha enviado a mensagem. Disse nunca ter traficado. Que naquele dia ele tinha droga na sua casa porque ele tinha apenas cortado um pedaço para amostra. Esclareceu que arrumou a droga na praça do bairro. Disse que pagou em torno de R\$ 800,00. Que iria vender em torno de R\$ 2.000,00, R\$ 2.200,00. Disse que é vendedor de mel. Que na época, perdeu a cabeça, e foi lá vender a droga. Disse que os policiais paravam sua esposa de moto perguntando sobre o processo. Disse que no momento da abordagem os policiais fizeram uma pressão. Que ao levá-lo até sua residência, o deixaram dentro do veículo, dizendo que tinham um saco de droga dentro do carro e que implantar. Para que ele falasse onde tinha arma. Disse que não autorizou a polícia entrar na sua casa. Disse que a sua esposa não possui CNH. Disse que tem notícia de que esses meses policiais prosseguiriam seu advogado, passando com viatura onde ele mora. Disse que está arrependido do crime. Que trabalha na Mustangue e na GDA. Pois bem.

"É certo que a comprovação exigida pelos delitos previstos nos artigos 33, "caput" e 28, da Lei de Drogas, não é de fácil constatação, sendo certo que, tal análise deve ter por base as provas extraídas da própria situação fática. Desse modo, para que não se cometam injustiças confundindo usuários com traficantes, para configuração das condutas criminosas previstas na Lei em comento, deverão ser analisadas a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do acusado. Também deve se levar em consideração a forma de acondicionamento da droga". (Apelação nº 0054000-21.2008.8.26.0114, Rel. Des. Borges Pereira, 16ª Câ. Direito Criminal).

De prêmio, não há qualquer dúvida que as drogas descobertas eram do réu, haja vista as circunstâncias em que foram encontrados os entorpecentes, além da própria confissão do acusado no sentido de que, após receber uma encomenda de drogas via whatsapp, visualizou a chance de ganhar um dinheiro na situação, sobretudo porque na época estava desempregado, decidindo realizar a venda mormente porque conhecia as pessoas necessárias para viabilização do negócio, tendo indo até uma praça adquirido grande quantidade de drogas de conhecidos, guardando parte em sua residência e levando consigo uma amostra para o momento da venda.

A controvérsia principal que surgiu com a tese defensiva diz respeito a existência do fato típico ou não em razão de possível flagrante preparado.

Nesse ponto, não ficou satisfatoriamente demonstrado nos autos que um dos policiais militares que realizou a abordagem no réu, ora também testemunha, Célio, manteve relacionamento amoroso com a atual esposa do acusado, passando a perturbá-la em razão do término, visto que a versão dela deve ser vista com reserva, em especial porque de um relacionamento, em especial hoje em dia, com as facilidades de armazenamento de comunicação, seria fácil comprovar o alegado, o que efetivamente não aconteceu.

Por outro lado, pelo laudo de comparação de Locutor, solicitado pela defesa para corroborar a tese de que a encomenda foi feita pelos próprios policiais militares para fins de viabilizar o flagrante, restou a conclusão que: A quantidade do material questionado limita as análises e diferentes abordagens que poderiam ser levadas a termo caso houvesse maior quantidade de material. Nesse sentido, é temerário qualquer resultado "em nível de identificação" sem que isso não signifique passar por cima das limitações inerentes ao material questionado. A pouca quantidade do material questionado também não permitiu que outros parâmetros, de alto poder identificativo, encontrados ao material padrão, fossem ali observados. Por outro lado, deve-se informar que o signatário encontrou similaridades em ambas as amostras (a audiência e o áudio da mensagem) e que tais similaridades são esperadas para um mesmo falante. Posto isso, considera-se que as evidências suportam fortemente a proposição de que os materiais questionados e padrão sejam oriundos de um mesmo falante. Tal nível de certeza foi alcançado segundo a aplicação de uma abordagem conhecida como combinada clássica. Tal

abordagem se formula por meio de análises robustas, construídas sobre a base da experiência do perito, cujos resultados são expressos mediante modelos qualitativos que representam níveis de suporte às duas proposições concorrentes (as de que as amostras sejam ou não oriundas de um mesmo falante, respectivamente), conforme se mostra no Quadro II. (fls. 362/364).

Diante de toda dúvida que cerca o episódio do flagrante, em homenagem ao princípio do favor rei, o estado flagrancial restou prejudicado, no que tange ao núcleo do tipo 'vender', sem que isso se configurasse o flagrante preparado.

Contudo, mesmo a figura do flagrante preparado deve ser analisada com atenção especial nos casos que envolvam tráfico de drogas – sem descartar o cuidado em relação a outros crimes permanentes. É que o tráfico de drogas é um crime cujo núcleo do tipo é misto ou alternativo, ou seja, pode se consumar com a prática de qualquer uma das várias ações descritas no tipo penal.

Veja que o caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Lei Antitóxicos) diz: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Isto é, ao mesmo tempo em que 'vender' drogas é uma das possíveis condutas realizadoras do tipo, também o é o fato de trazê-las consigo, guardar ou transportar (condutas de natureza permanente). Com isso, se a venda da substância não fosse ocorrer, o crime de tráfico já estava consumado pelo fato de o agente adquirir, guardar e trazer as drogas consigo para venda. A aquisição, a guarda e o porte das drogas pelo traficante é fato pretérito e completamente independente da ação do policial (sem interferência do agente provocador), razão pela qual a prisão em flagrante será válida – não pela 'venda' em si (esta de vontade viciada), mas por eventual 'depósito', 'guarda' etc.

Se o agente já 'tinha em depósito', já 'guardava', 'transportava' ou 'trazia consigo' a droga antes mesmo de ser instigado a vender ao policial, já incorria em flagrante nessas condutas de natureza permanente, nos termos do art. 303 do CPP:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

A atuação policial só faz caracterizar (em termos de provas) a infração penal, que já ocorria anteriormente. Assim, o flagrante será por alguma dessas outras condutas pretéritas e não pela 'venda' ao policial. Indo mais longe e mudando o exemplo, poderíamos concluir, então, que se o agente não dispusesse da droga naquele momento e fosse adquirir apenas para 'revender' ao policial, aí sim incidiríamos em crime impossível e/ou flagrante preparado, o que não foi o caso.

Nesse sentido, conferir:

“APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória Preliminar de ocorrência de crime impossível em razão do flagrante forjado ou preparado Afastamento Crime permanente - Absolvição Desclassificação para consumo próprio Descabimento Materialidade e autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo, transportavam e guardavam a droga apreendida para fins de tráfico Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 para o corréu Caio, uma vez que é reincidente, cabível pra os demais apelantes Regime fechado para o corréu Daniel adequado e compatível com a gravidade do crime e a reincidência do réu. Alteração para o regime aberto no tocante aos demais réus compatível com o quantum da reprimenda imposta, em consonância com o atual entendimento firmado nas Cortes Superiores Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da reprovabilidade da conduta perpetrada PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)” (TJSP nº 0003089-12.2019.8.26.0666, Relatora, FÁTIMA GOMES, Data de Julgamento: 17/02/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2021);

“Também não há que se reconhecer o alegado flagrante forjado, na medida em que o

crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das dezoito ações identificadas em seu núcleo típico, todas de natureza permanente, de modo que, preexistentes à atuação policial, legitimam a prisão em flagrante, sem que se possa cogitar do flagrante forjado ou preparado" (TJSP 0009256-26.2011.8.26.0278, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 23/06/2016, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/06/2016).

Com isso, afasto a tese de flagrante preparado.

Quanto à caracterização do tráfico de drogas, ressalto que a figura típica prevista no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 não exige que as condutas descritas tenham uma finalidade específica (comércio de droga), ou seja, não há elemento subjetivo específico do tipo, mas apenas o elemento subjetivo geral consistente no dolo (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2.ed. p. 316).

Assim, basta a vontade livre e consciente de realizar uma das condutas previstas no tipo penal, independentemente da finalidade específica de comércio ou enriquecimento. Por outro lado, a doutrina e a jurisprudência recomendam a desclassificação do tráfico de droga (art. 33 da LD) para o porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da LD) quando assim indicarem as seguintes circunstâncias: quantidade da droga apreendida, antecedentes criminais do agente (principalmente ligados ao tráfico) e comércio de droga.

Nesse sentido: Nucci, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2.ed. p. 318. Da mesma forma, o art. 28, § 2º da Lei de Drogas estabelece quais circunstâncias devem ser consideradas para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal (natureza e quantidade da substância apreendida; local e condições em que se desenvolveu a ação; circunstâncias sociais e pessoais; conduta e antecedentes do agente).

No caso dos autos, conforme acima exposto, a prova contida nos autos revelou que o acusado adquiriu, trazia consigo e guardava, certa quantidade de droga (maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 33, caput da LD). Além disso, a quantidade (20 invólucros de maconha e um tijolo da mesma droga) e a forma de acondicionamento da droga indicam a traficância e corroboram a prova testemunhal.

Diante do exposto, não há se falar em insuficiência de provas, motivo pelo qual a condenação é de rigor.

Para que não fique sem referência, no tocante ao requerimento de Trancamento da Ação Penal, haja vista a falta de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, descabida adoção de qualquer postura por este Magistrado. É que, sendo o enunciado 12 da 1ª JORNADA DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL CJF/STJ: A proposta de acordo de não persecução penal representa um poder dever do Ministério Público, com exclusividade, desde que cumpridos os requisitos do art. 28-A do CPP, cuja recusa deve ser fundamentada, para propiciar o controle previsto no § 14 do mesmo artigo. No caso dos autos, houve a recusa do MP, tendo ocorrido, outrossim, remessa dos autos ao Procurador Geral do Estado de São Paulo, nos termos do art. 28-A, § 14 do Código de Processo Penal (fl. 188), sendo juntada a manifestação em 18/01/2021 (fls. 192/201), conforme requerido pela defesa, que, por sua vez, insistiu no não Acordo, pelos sob o fundamento de que o acusado não confessou formal e circunstanciadamente a prática do crime, não estando preenchido outro requisito objetivo, tendo em vista que se trata de infração penal com pena mínima superior a 4 (quatro) anos, já que se cuida de imputação de crime de tráfico de drogas, na modalidade fundamental (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06). E que, em casos tais, ademais, revelava-se descabido o pedido de revisão, nos termos do Enunciado n.º 29, PGJ – CGMP – Lei n.º 13.964/19.

Pois bem. No Brasil, se o Ministério Público se negar a propor o anpp, o investigado pode requerer a remessa dos autos ao órgão superior do próprio MP. Se houver a insistência no não oferecimento, o juiz e o agente nada poderão fazer, mesmo se verificado que a negativa do Parquet é infundada.

Por fim, também anoto que não é caso de reconhecimento da suspeição do membro do Ministério Público, porquanto, conforme já explicado, o flagrante preparado se deu tão somente em razão do verbo vender, certo que qualquer outra providência a ser

tomada nesse aspecto nada diz respeito ao presente feito. Além do mais, a não oferta do Acordo de Não Persecução Penal se pautou em próprio entendimento interno da instituição.

Aplicável o disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, visto que o réu é primário e possui bons antecedentes.

APLICAÇÃO DA PENA.

1) Tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), o acusado não possui maus antecedentes, tendo em vista inexistir condenação transitada em julgado, a qual já passou pelo período depurador, é penalmente imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar sua capacidade de conhecer a ilicitude de sua ação e de determinar-se de acordo com ela. A culpabilidade consubstanciada no grau de reprovabilidade não está acima da média. A conduta social não foi bem delineada nos autos. Sua personalidade não aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime. Desta forma a pena-base deve ser fixada no mínimo legal em 05 anos de reclusão.

2) O acusado confessou a prática do delito. Nesse ponto seria caso de compensação proporcional, com diminuição da pena base. Contudo a pena inicial foi fixada no mínimo legal, pelo que a mantenho.

“3) Na terceira e derradeira fase, merece acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. É que o réu é primário, ostenta bons antecedentes e não há fundadas notícias de que ele se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Quanto ao redutor de pena, tenho que a quantidade de droga não destoa da normalidade, sendo que o contexto dos autos não revelou habitualidade delituosa, pelo que aplico o redutor em seu patamar máximo e justifica a diminuição da pena no quantum intermediário de dois quintos. Não há causas de aumento. Assim, fixo a pena definitiva em 1 ano e 08 meses de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico. Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada no mínimo legal, ou seja, 500 dia-multa. No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos moldes do art. 33, §1º, 'c', do CP, que, no caso, não resta alterado pela aplicação do art. 387, §2º, do CPP.

No ponto, incumbe registrar que, por força do teor da Súmula nº. 440 do STJ, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base na gravidade abstrata do delito, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso, conquanto a quantidade de droga não seja reduzida, a natureza da substância e as demais condições judiciais absolutamente favoráveis não impedem a concessão da benesse, que, no caso, é a medida que mais atende aos fins ressocializadores e retributivos da sanção penal.

Ademais, conquanto originariamente o art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 vedasse a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos, o STF, no julgamento do HC 97.256/RS, julgou inconstitucional tal previsão por violação ao direito fundamental de individualização da pena. Posteriormente, foi publicada a Resolução nº. 5 do Senado Federal, que, com efeito erga omnes, suspendeu a vedação legal e impôs ao julgador o dever de verificar a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CP.

Nessa linha, tendo em vista que, no caso, o réu é primário, que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça e que as circunstâncias judiciais são favoráveis, imperiosa é a conversão da pena privativa de liberdade por duas

restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, da Lei 11.343/06, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais, e de prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser paga à entidade pública ou privada com destinação social determinada pelo Juízo da execução. A duração da pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser igual àquele da pena privativa de liberdade, e a de prestação pecuniária não substitui a pena multa.

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva ajuizada pelo Ministério Público e o faço para CONDENAR o réu FABIO DE OLIVEIRA DOTTI, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Condeno-o, ainda, à pena pecuniária de 500 dias-multa, fixados no valor mínimo legal (art. 43 da LD), cada um deles no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de liberdade de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a ser paga a entidade pública ou privada com destinação social, tudo na forma a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, poderá recorrer em liberdade.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos, e, com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido às fls. 40.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena imposta, bem como as comunicações (IIRGD, TRE e VÍTIMA - artigos 393, inciso V, 398 e 399, das NSCGJ) e anotações necessárias no sistema informatizado (art. 372 das NSCGJ). O condenado deve pagar custas processuais (art. 804 do CPP), nos termos da legislação estadual, cuja exigibilidade ficará suspensa.

P.I.C

Catanduva, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA